

Bloque 1 - Tema 6

FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO. LA JERARQUÍA DE LAS FUENTES. LA LEY. LAS DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO CON FUERZA DE LEY: DECRETO-LEY Y DECRETO LEGISLATIVO. EL REGLAMENTO: CONCEPTO, CLASES Y LÍMITES. OTRAS FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

PREPARACIÓN OPOSICIONES

TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA

ÍNDICE

ÍNDICE	2
1. FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO	3
1. Clasificación de las fuentes del derecho	4
2. LA JERARQUÍA DE LAS FUENTES	6
3. LOS TRATADOS INTERNACIONALES	9
4. LA LEY	11
1. Leyes orgánicas	14
2. Leyes ordinarias	15
3. Estatutos de Autonomía	16
4. Leyes básicas, marco, de transferencia o de delegación y armonizadoras	17
5. Leyes de las CCAA	17
5. DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO CON FUERZA DE LEY	19
1. Decreto Legislativo	19
2. Decreto-Ley	20
3. Analogías y diferencias	21
4. Control de la legislación delegada	22
6. EL REGLAMENTO: CONCEPTO, CLASES Y LÍMITES	23
1. Clases de Reglamentos	23
2. Límites de la potestad reglamentaria	25
3. Reglamentos ilegales	27
7. OTRAS FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO	28
1. Normas directas no escritas	28
2. Normas indirectas	28
3. Derecho comunitario	29

1. FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

Marco normativo:

- Constitución Española (CE).
- Código Civil (CC).
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP. (LPACAP).
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).
- Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (LG).

Se entiende por fuentes del Derecho Administrativo **aquellas normas o actos a través de los cuales éste manifiesta su vigencia.**

Según el art. 1.1 del CC, las fuentes del ordenamiento jurídico español son:

- La **ley**.
- La **costumbre**.
- Los **principios generales del Derecho**.

La **COSTUMBRE** sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público, y que resulte probada. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad, tendrán la consideración de costumbre (art. 1.3 CC).

Los **PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO** (pgD) se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico (art. 1.4 CC).

Los pgD tienen una triple función:

- Fundamentadores del ordenamiento jurídico: ideas o nociones fundamentales que lo inspiran.
- Orientadores en la labor de interpretación de la Ley: permiten un recto entendimiento de las normas mediante elementos de ética, equidad, lógica y sentido de la realidad y de la justicia.
- Supletorios: aplicándose en defecto de ley o costumbre para cubrir el vacío producido.

Las normas jurídicas contenidas en los **tratados internacionales** NO serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el BOE (art. 1.5 CC).

La **jurisprudencia** complementará el ordenamiento jurídico con la **doctrina** que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho (art. 1.6 CC).

Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido (art. 1.7 CC).

1. Clasificación de las fuentes del derecho

Las fuentes del derecho se pueden clasificar en:

- Fuentes directas e indirectas.
- Fuentes escritas y no escritas.
- Fuentes primarias y subsidiarias.
- Fuentes en sentido formal y en sentido material.

(1) Fuentes directas e indirectas

Fuentes **DIRECTAS**: de aplicación directa.

- Constitución Española.
- Tratados internacionales publicados en el BOE.
- Leyes orgánicas y ordinarias.
- Normas con fuerza de Ley:
 - o Decretos-leyes.
 - o Decretos Legislativos.
- Reglamentos:
 - o Decretos del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros.
 - o Orden Ministerial.
- Costumbre.
- Principios generales del Derecho.

Fuentes **INDIRECTAS**:

- Jurisprudencia del Tribunal Supremo.
- Tratados internacionales no publicados en el BOE.
- Doctrina científica.

(2) Fuentes escritas y no escritas

Fuentes **ESCRITAS**: primacía sobre las fuentes no escritas.

- Constitución Española.
- Ley.
- Normas con fuerza de Ley
- Reglamentos.

Fuentes **NO ESCRITAS**:

- Costumbre.
- Principios generales del Derecho.

(3) Fuentes primarias y subsidiarias

Fuentes **PRIMARIAS**: aplicables siempre que concurren los supuestos de hecho por ellas contemplados.

- Constitución Española.
- Ley.
- Normas con fuerza de Ley.
- Reglamentos.

Fuentes **SUBSIDIARIAS**: aplicables en defecto de fuentes primarias.

- Costumbre.
- Principios generales del Derecho.

(4) Fuentes en sentido material y formal

Fuentes en sentido **MATERIAL**: son aquellas instituciones o fuerzas sociales que poseen capacidad para crear o producir normas jurídicas.

Fuentes en sentido **FORMAL**: son los modos a través de los cuales se manifiesta el derecho (ley, reglamento, costumbre, etc.).

2. LA JERARQUÍA DE LAS FUENTES

El principio de **JERARQUÍA NORMATIVA** aparece recogido en el art. 9.3 de la CE. Asimismo, el Código Civil lo recoge en su art. 1.2 al disponer que: “*carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior*” (**dimensión vertical**)

En virtud de este principio:

- Las normas de rango superior prevalecen y se imponen sobre las de rango inferior.
- Las normas que ostentan el mismo rango tienen la misma fuerza normativa.

Tener en cuenta,

- **La primacía del Derecho escrito.** Las fuentes escritas del Derecho Administrativo gozan de primacía sobre las no escritas, es decir, la costumbre y los principios generales del Derecho.
- **La jerarquía del órgano del que emana la regla escrita de Derecho.** Sin perjuicio de la supremacía de la Constitución respecto de las leyes orgánicas y ordinarias, ha de tenerse en cuenta que a mayor jerarquía del órgano que dicta la norma administrativa, mayor valor de la norma dictada. Como consecuencia, el principio de jerarquía normativa permite constatar la relación existente entre la fente de la que emana cada norma (el órgano que la produce) y la forma de esta, así como su rango y fuerza.

Así pues, las Cortes Generales al tener atribuida la potestad legislativa (art. 66.2 de la CE) las normas que aprueban son Leyes, el Gobierno Reglamentos, etc.

El principio de **COMPETENCIA** hace referencia al nivel territorial que tiene atribuida la competencia para la producción normativa en una materia concreto (**dimensión horizontal**).

Este principio surge al tener distintos niveles de Administración: estatal, autonómica, etc.

Estos dos principios son fundamentales y se aplican de la siguiente manera:

- Dentro de una misma Administración (ya sea la estatal o ya sea autonómica) las normas se ordenan por el principio de jerarquía normativa.
- Para las normas de distintas Administraciones, se aplica el principio de competencia y no el de jerarquía.

Como ya sabemos, en el art. 148 de la CE se listan las materias sobre las que una CCAA puede asumir competencia (y que aparecerán recogidas en su respectivo Estatuto de Autonomía). Y en el art. 149 de la CE se enumeran las materias de competencia exclusiva estatal. Es decir, las CCAA pueden legislar sobre unas materias y el Estado sobre otras.

Ello significa que las leyes de las CCAA jerárquicamente no están ni por encima ni por debajo con respecto a las leyes del Estado, sino que están en planos diferentes, al aplicarse el principio de competencia.

Consecuencia de tener distintas Administraciones, de las competencias atribuidas a cada una de ellas y en relación con la regulación constitucional de las CCAA, surge el principio de supletoriedad.

El **principio de SUPLETORIEDAD** establece que el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las CCAA (art. 150.3 CE)

Ejemplo: El Estado tiene competencia exclusiva sobre bases del régimen de los funcionarios (art. 149.1.18º) y la CCAA el desarrollo legislativo y ejecución (por ejemplo, Estatuto de Autonomía de Andalucía, art. 76).

Entonces, la supletoriedad significa, que para todo lo no regulado por una CCAA en materia de su competencia, será de aplicación la legislación estatal.

De acuerdo con el art. 149.3 CE, segunda frase, “...al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las CCAA en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas.”

El **principio de PREVALENCIA**, relacionado con resolución de colisiones normativas, tiene como característica esencial producir la inaplicación de la norma autonómica válida que se opone a la norma estatal válida sin afectar, sin embargo, a la validez de la norma inaplicada.

Pirámide jerarquía normativa estatal

Corresponde a la CE determinar las potestades normativas y la atribución del rango en virtud de la fuente de la que proceden. De esta forma todas las normas procedentes de la misma fuente tienen, en principio, la misma forma externa y la misma fuerza (leyes, decretos, etc.).

En virtud de ello se configura una estructura piramidal, cuya cúspide es la CE, norma suprema que prevalece y se impone a todas las demás.

En segundo lugar, se hallarían los Tratados Internacionales publicados en el BOE.

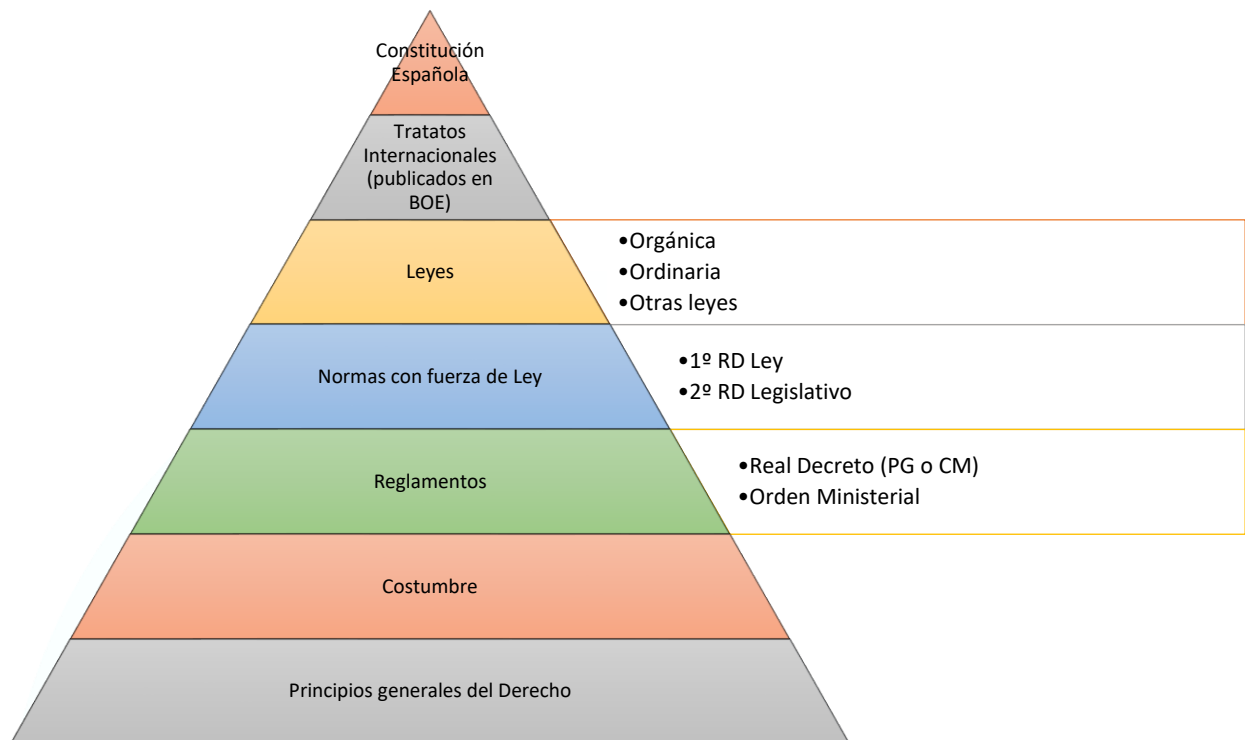
En tercer lugar, se encuentran las leyes y las disposiciones del Gobierno con rango o fuerza de Ley (Decretos-Leyes y Decretos Legislativos).

El siguiente escalón lo constituyen los Reglamentos.

Hasta aquí tenemos jerarquizadas las fuentes directas y escritas. Por último y según establece el CC, quedan los dos últimos escalones, ocupados por la Costumbre y los pgD.

Recordamos que las normas de un escalón inferior no pueden contradecir (vulnerar) las normas de un escalón superior.

Se muestra a continuación la estructura piramidal jerarquizada a nivel estatal:



3. LOS TRATADOS INTERNACIONALES

Un **TRATADO INTERNACIONAL** es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de Derecho internacional y que se encuentra regido por éste, que puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos conexos, siendo indiferente su denominación.

Los Tratados Internacionales están regulados en la CE: Capítulo Tercero “De los Tratados Internacionales” del Título III “De las Cortes Generales” (arts. 93-96).

Consentimiento

Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes (art. 63.2 CE).

Aprobación

Existen 3 mecanismos de aprobación dependiendo de qué tipo de materias se regulen en el Tratado:

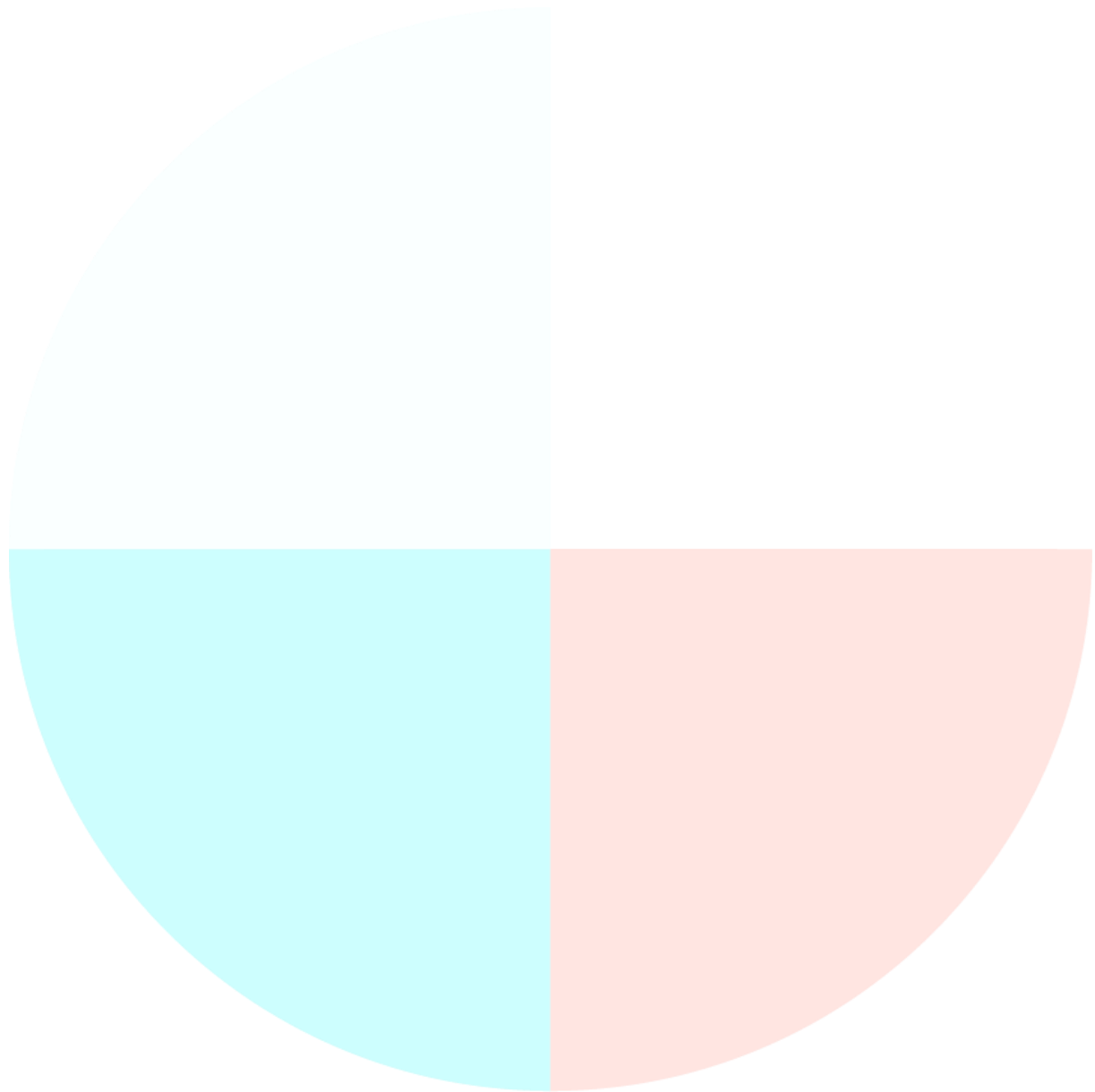
- Mediante Ley Orgánica se autorizará la celebración de Tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución.
- El Gobierno podrá prestar el consentimiento del Estado para obligarse por medio de Tratados o convenios con la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos:
 - Tratados de carácter político.
 - Tratados o Convenios de carácter militar.
 - Tratados o Convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I.
 - Tratados o Convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.
 - Tratados o Convenios que supongan modificación o derogación de alguna Ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.
- En el resto de materias sólo será necesario informar inmediatamente al Congreso y al Senado de la conclusión.

Incorporación al ordenamiento jurídico

Una vez que un Tratado Internacional ha sido incorporado a nuestro ordenamiento jurídico: *“Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno”* (art. 96.1 CE), es cuando se sitúan en la jerarquía normativa justo debajo de la Constitución Española y por encima de las leyes. Mientras no se cumpla lo dispuesto en este art. se considera una fuente indirecta.

Revisión

“Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios Tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional. Para la denuncia de los Tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación” (art. 96 CE).



4. LA LEY

Se puede definir la **LEY** como toda norma escrita emanada del poder que tiene atribuida la suprema potestad legislativa, las Cortes Generales o Asambleas Legislativas de las CCAA, como órgano de expresión de la soberanía popular.

La característica más acusada del concepto de ley en sentido formal es la de su valor añadido, al distinguirse de las restantes normas por su especial fuerza y por el rango que ocupa en la jerarquía normativa, ya que sólo tiene como límite los preceptos constitucionales.

Tras la aprobación, sanción y promulgación (art. 91 CE), las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el BOE, si en ellas no se dispone otra cosa (art. 2.1 CC).

El **principio de SUCESIÓN CRONOLÓGICA** significa que las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que, en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior (**dimensión temporal**).

Cabe resaltar, que por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado (art. 2.2 CC).

Asimismo, las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario (art. 2.3 CC).

Tener en cuenta, que el art. 9.3 de CE establece la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

El **principio de ESPECIALIDAD NORMATIVA** parte del supuesto de contradicción entre dos normas vigentes, una general y otra especial, en el mismo nivel territorial y para la misma materia y tiene como resultado la persistencia de la vigencia simultánea de ambas normas, si bien la ley especial se aplicará con preferencia a la ley general en aquellos supuestos contemplados (**dimensión de profundidad**).

Ejemplo: Ley 39/2015 es la norma general. En su Disposición adicional primera se regulan las especialidades por razón de materia y establece que se aplicará la normativa específica en materia tributaria y aduanera, en Seguridad Social, etc. Por tanto, tenemos una ley general que regula el procedimiento administrativo y normas específicas para materias concretas.

El **principio de RESERVA DE LEY** significa que algunas materias sólo pueden ser reguladas por una ley.

La CE formula, de manera sistemática, principios de reserva de ley a lo largo de todo su articulado. Así, destacamos:

- En el Título Preliminar, artículos:
 - 6 (regulación de partidos políticos).
 - 7 (regulación de sindicatos)

- 8 (bases de la organización militar).
- En el Título I, artículos:
 - 11 (nacionalidad).
 - 12 (extranjería).
 - 14 al 29.
 - 30 (servicio militar y objeción de conciencia).
 - 31 (tributos).
 - 32 (matrimonio y su disolución).
 - 33 (expropiación forzosa y régimen de la propiedad).
 - 34 (fundaciones).
 - 35 (Estatuto de los Trabajadores).
 - 36 (colegios profesionales).
 - 37 (negociación colectiva).
 - 38 (libertad de empresa y economía de mercado).
 - 45 (sanciones administrativas y penales).
 - 54 (defensor del pueblo).
 - 55 (suspensión de ciertos derechos en la investigación de la actuación de bandas armadas y terroristas).
- En el Título II, artículos:
 - 57 (sucesión a la Corona).
 - 59 (reconocimiento de la inhabilitación del Rey).
 - 62 (regulación del derecho de gracia).
 - 63 (declaración de guerra y paz).
- En el Título III, artículos:
 - 68 y 69 (elecciones para el Congreso y el Senado).
 - 70 (incompatibilidades e incapacidades para ser elegidos).
 - 82 (leyes de bases y leyes que delegan refundiciones).
 - 87 (iniciativa popular).
- En el Título IV, artículos:
 - 103 (bases de la organización administrativa).
 - 104 (Cuerpos y Fuerzas de Seguridad).
 - 105 (participación ciudadana).
 - 106 (responsabilidad patrimonial del Estado).
 - 107 (Consejo de Estado).

- En el Título V, artículos:
 - o 116 (regulación de los estados de alarma, sitio y excepción).
- En el Título VI, artículos:
 - o 117 (inamovilidad de los jueces).
 - o 121 (responsabilidad del Estado por error judicial).
 - o 122 (Ley Orgánica del Poder Judicial).
 - o 124 (Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal).
 - o 125 (institución del Jurado).
- En el Título VII, artículos:
 - o 128 (reserva al sector público de recursos o servicios esenciales).
 - o 129 (participación ciudadana en la Seguridad Social).
 - o 131 (planificación de la actividad económica y Consejo Económico-Social).
 - o 132 (regulación del Patrimonio del Estado y Patrimonio Nacional).
 - o 133 (establecimiento de tributos y beneficios tributarios).
 - o 134 (Presupuestos Generales del Estado).
 - o 135 (estabilidad presupuestaria).
 - o 136 (Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas).
- En el Título VIII, artículos:
 - o 140 (régimen de los municipios).
 - o 141 (alteración de los límites provinciales).
 - o 145 (acuerdos de cooperación entre CCAA).
 - o 146 (aprobación de Estatutos de Autonomía).
 - o 147 (reforma de Estatutos).
 - o 149 (lista de competencias exclusivas del Estado, con gran nº de materias reservadas a la ley).
 - o 150 (leyes marco, de transferencias a las CCAA y de armonización).
 - o 151 (referéndum autonómico).
 - o 155 (obligaciones impuestas a las CCAA).
 - o 157 (ejercicio de competencias financieras por las CCAA).
- En el Título IX, artículos:
 - o 161 (atribución de competencias al Tribunal Constitucional).
 - o 162 (legitimación para interponer recursos de inconstitucionalidad y amparo).
 - o 165 (LOT).

De esta larga enumeración extraída de los preceptos constitucionales, puede inducirse:

- 1) Una clara tendencia a que los contenidos más relevantes del ordenamiento sean reservados a la ley formal y que, por tanto, queden excluidos de la potestad reglamentaria.
- 2) En particular, de este principio resulta sencillo inferir que cuando existe una mención expresa de alguna materia como reservada a la ley, otras no aludidas, pero más o menos análogas, habrán de entenderse también incluidas en dicha reserva; por ejemplo, el art. 140 reserva a la ley el régimen de los municipios y en cambio el art. 141 no dice lo mismo respecto a las provincias, salvo en cuanto a sus límites geográficos; parece claro que no podrá deducirse de esta diferencia que el régimen básico de las provincias no sea materia de ley.
- 3) Pero sobre todo, y aparte la materia organizativa, dentro de esta lista casuística destaca un precepto básico, el del art. 53.1 de la Constitución, que tiene un claro alcance general y en el que hay que situar necesariamente la regla fundamental sobre el tema de la reserva de ley en nuestro sistema. El art. 53.1 dispone que:

“Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades”.

Por su parte las **CCAA** también tienen capacidad para dictar normas con rango de Ley, según lo dispuesto en sus correspondientes Estatutos de Autonomía.

Conviene recordar que todas las leyes tienen el mismo rango o jerarquía, pero distintos procedimientos y ámbitos de aplicación.

Los tipos de leyes son:

- Leyes orgánicas.
- Leyes ordinarias.
- Leyes básicas.
- Leyes marco.
- Leyes de transferencia o de delegación.
- Leyes armonizadoras.

1. Leyes orgánicas

La figura de las leyes orgánicas es una de las novedades más sobresalientes de la Constitución de 1978 y, también, una de las más complejas y discutibles.

En una primera aproximación, pueden describirse como un tipo especial de leyes para cuya aprobación se requiere un quórum especialmente reforzado en el Congreso de los Diputados, por referirse a materias a las que la Constitución otorga una particular relevancia.

Son, pues, dos las notas que las caracterizan:

1) Una nota **MATERIAL** (el ámbito a que se refiere):

Son leyes orgánicas (art. 81.1 CE):

- Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
- Las que aprueben los Estatutos de Autonomía.
- Las que aprueben el régimen electoral general.
- Las demás previstas en la CE.

En relación con la expresión “las demás previstas en la CE”, se debe señalar que se regulan por este tipo legal las siguientes materias:

- La organización militar.
- El Defensor del Pueblo.
- La suspensión de derechos y libertades.
- La sucesión a la Corona.
- La iniciativa popular y las modalidades de referéndum.
- Los tratados internacionales que otorguen competencias internacionales.
- Las funciones y principios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
- El Consejo de Estado.
- Los estados de alarma, excepción y sitio.
- El Poder Judicial.
- El Tribunal de Cuentas.
- La constitución de Comunidades Autónomas.
- La aprobación y reforma de Estatutos de Autonomía.
- Transferencia de competencias de titularidad estatal.
- El Tribunal Constitucional.
- El régimen electoral.

2) Una nota **FORMAL** (el procedimiento de elaboración): la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá **mayoría absoluta del Congreso**, en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81.2 CE).

2. Leyes ordinarias

Es la forma común de las disposiciones con rango de ley, cuyo ámbito comprende todas las materias no reservadas a la ley orgánica. Así pues, el ámbito material de las mismas se define por "exclusión" con respecto a leyes orgánicas.

Las leyes ordinarias se aprueban por la mayoría (simple) de los miembros presentes siempre que las Cámaras estén reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros (art. 79 CE).

Para la elaboración y aprobación de una ley, es necesario que los órganos tengan atribuida la competencia de la **iniciativa legislativa**, que según el art. 87 CE son:

- El **Gobierno**: proyecto de ley.
- El **Congreso**: proposición de ley.
- El **Senado**: proposición de ley.
- **Asambleas de las CCAA**: pueden solicitar al Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley.
- El **pueblo**: proposición de ley. Materias excluidas:
 - o Las reservadas a Ley orgánica.
 - o Tributarias.
 - o Carácter internacional.
 - o Prerrogativa de gracia.
 - o Reforma constitucional.
 - o Presupuestos Generales del Estado.

3. Estatutos de Autonomía

Un **ESTATUTO DE AUTONOMÍA** es la norma institucional básica española de una Comunidad Autónoma, reconocida por la CE y cuya aprobación se lleva a cabo mediante Ley Orgánica.

En él se recogen, al menos, la denominación de la Comunidad, la delimitación territorial, la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas y las competencias asumidas (art. 147.2 CE). Los Estatutos de Autonomía no son expresión de soberanía ni son una Constitución pues no nacen de un poder constituyente originario, (del que carecían los territorios que se constituyeron en CCAA), sino que deben su existencia a su reconocimiento por el Estado sin que en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad.

Los Estatutos se encuentran en dos estructuras jerárquicas:

- **Estatutal**: pertenece al rango de las leyes. Se aprueban por Ley Orgánica.
- **Autonómica**: es la cúspide, primer escalón, de la jerarquía autonómica.

4. Leyes básicas, marco, de transferencia o de delegación y armonizadoras

Son modalidades particulares de leyes estatales.

Leyes básicas

Son las leyes dictadas por las Cortes Generales, para aquellas competencias sobre las que el Estado tiene potestad legislativa básica, pero son las CCAA las encargadas de su ejecución y desarrollo legislativo.

En el art. 149 de la CE, relativo a las competencias exclusivas del Estado, se definen aquellas materias para las que el Estado solo tiene la potestad legislativa básica.

Por ejemplo, son leyes básicas las que regulan las bases del régimen jurídicos de las AAPP o el régimen estatutario de los funcionarios.

Leyes MARCO

Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las CCAA la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las CCAA (art. 150.1 CE).

Leyes de TRANSFERENCIA o DE DELEGACIÓN

El Estado podrá transferir o delegar en las CCAA, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado (art. 150.2 CE).

Leyes ARMONIZADORAS

El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las CCAA, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad (art. 150.3 CE).

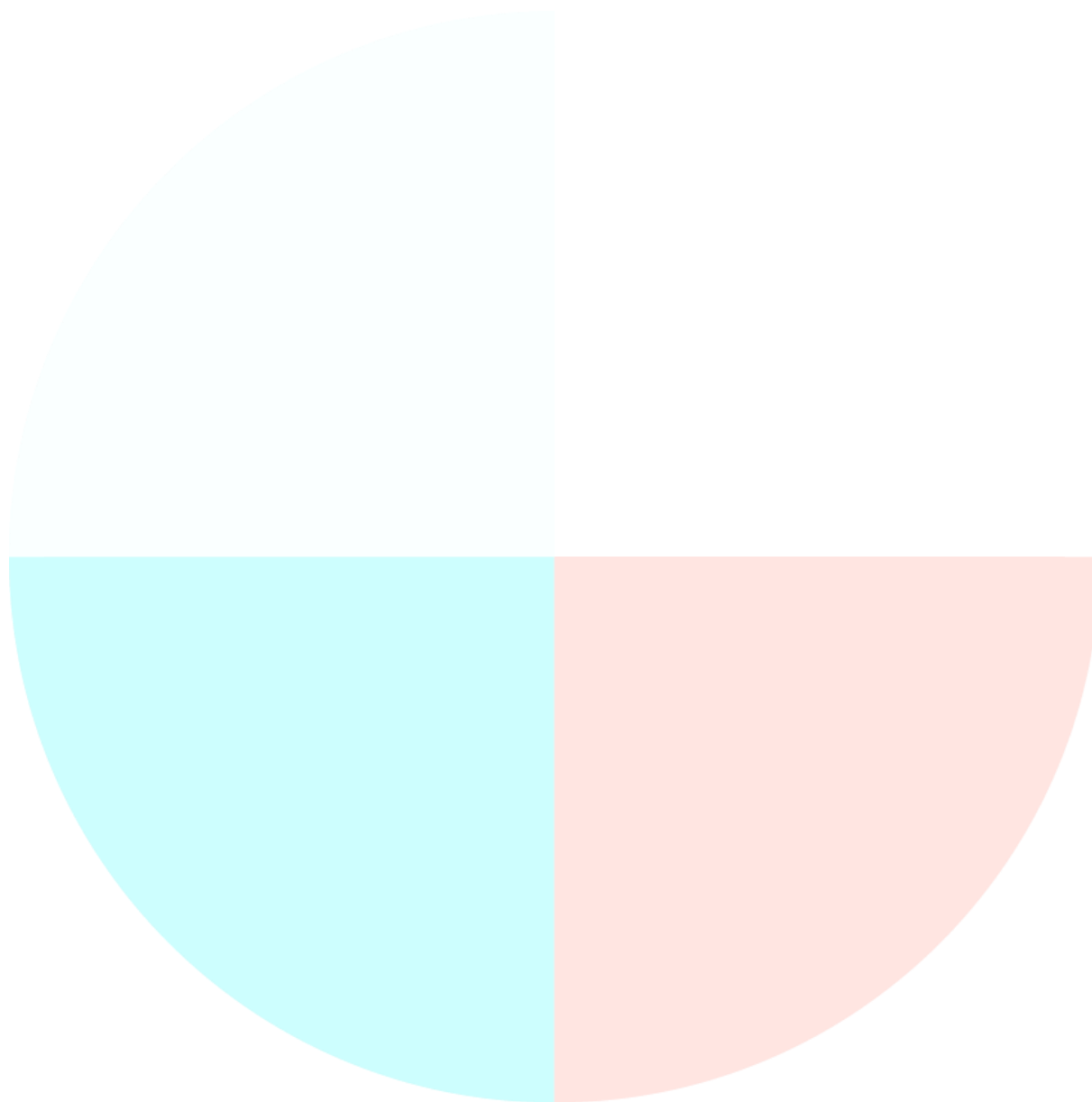
5. Leyes de las CCAA

Este tipo de leyes, como ya se comentó en apartados anteriores, se encuentran en un plano diferente al resto de tipos de leyes estatales, ya que no se relacionan entre sí por el principio de jerarquía normativa, sino por el principio de competencia.

El hecho de que las CCAA tengan atribuida la potestad legislativa, queda evidenciado en el art. 153 de la CE:

El control de la actividad de los órganos de las CCAA se ejercerá:

- a) *Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley.*



5. DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO CON FUERZA DE LEY

Junto a las leyes emanadas de las Cortes Generales, existen en nuestro ordenamiento jurídico otras normas con **rango y valor de Ley** que emanan del **Gobierno**.

En nuestro ordenamiento jurídico tienen este carácter:

- Los Decretos legislativos.
- Los Decretos-leyes.

1. Decreto Legislativo

Se trata de una delegación legislativa que a favor del Gobierno hace el poder legislativo (Cortes Generales).

La **LEGISLACIÓN DELEGADA** viene expresamente recogida en la CE. En concreto: *“Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el art. anterior”* (Ley Orgánica) (art. 82.1 CE).

Materias excluidas (art. 81.1 CE):

- Desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
- Estatutos de Autonomía.
- Régimen electoral general
- Las demás previstas en la Constitución (materias reguladas por Ley Orgánica).

Según el art. 82.2 de la CE, podemos distinguir 2 tipos de legislación delegada:

- Textos refundidos.
- Textos articulados.

Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de **Decretos Legislativos** (art. 85 CE).

La delegación legislativa habrá de otorgarse (art. 82.3 CE):

- Al Gobierno: no se permite la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.
- De forma expresa: no puede ser concedida de modo implícito.
- Para materia concreta: respetando las materias excluidas.
- Con fijación del plazo para su ejercicio: no puede entenderse concedida por tiempo indeterminado.

Textos REFUNDIDOS

Cuando existen multitud de textos legales que regulan una misma materia, se puede delegar en el Gobierno la facultad de **unificar o refundir tales textos en uno**, con el objetivo de simplificar la legislación vigente en una materia concreta. Como ejemplo, podemos citar el TREBEP.

Es importante resaltar que no se faculta al Gobierno para dictar nuevas normas, solo para refundir las ya existentes.

La delegación legislativa se **otorga mediante ley ordinaria**, cuando se trate de **refundir varios textos legales en uno solo** (art. 82.2 CE).

Textos ARTICULADOS

Proceden de una delegación que confieren las Cortes Generales al Gobierno para que redacte una Ley conforme a unas **BASES**. Como ejemplo, la Ley sobre Tráfico.

Se trata de una delegación más amplia que la del caso anterior, ya que se realiza aquí una auténtica **función creativa** de normas, si bien tal creación no es libre, sino que ha de ajustarse a las Bases dadas.

La delegación legislativa deberá **otorgarse mediante una Ley de Bases** cuando su objeto sea la formación de textos articulados (art. 82.2 CE).

Las leyes de bases:

- Delimitarán con precisión (art. 82.4 CE):
 - El objeto y alcance de la delegación legislativa.
 - Los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio.
- No podrán en ningún caso (art. 83 CE):
 - Autorizar la **modificación** de la propia Ley de Bases.
 - Facultar para dictar normas con carácter **retroactivo**.

2. Decreto-Ley

Son disposiciones con rango de Ley que emanan, por vía de **excepción**, de un órgano que no tiene atribuido el poder legislativo, concretamente del Gobierno o Consejo de Ministros.

Regulado en el art. 86 de la CE: *En casos de **extraordinaria y urgente necesidad** el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas **provisionales** que tomarán la forma de Decretos-Leyes y que NO podrán afectar:*

- Al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado,

- A los derechos, deberes y libertades fundamentales de los ciudadanos regulados en el Título I,
- al régimen de las CCAA,
- al Derecho electoral general.

Los Decretos-Leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los **30 días siguientes** a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.

Durante el plazo de los 30 días siguientes, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

Los Decretos-Leyes se caracterizan:

- El órgano del que emanan es el Gobierno.
- Equiparación absoluta a la Ley en sentido formal, mientras no sea derogado por el Congreso.
- El Gobierno ofrece una auténtica potestad legislativa «provisional».
- Hay una serie de materias reservadas a la Ley y expresamente prohibidas al Decreto-Ley.

3. Analogías y diferencias

De todo lo expuesto cabe señalar diversas analogías y diferencias entre los Decretos-Leyes y los Decretos Legislativos.

Analogías:

- Emanan del Gobierno.
- Tienen el mismo rango jerárquico, valor de Ley.

Diferencias:

- En los motivos: en cuanto que el Decreto-Ley exige la existencia de una situación excepcional y el Decreto Legislativo no.
- El momento de la intervención de las Cortes Generales, ya que en el Decreto Legislativo dicha intervención es previa, mientras que en el Decreto-Ley es posterior y con el carácter convalidante o derogatorio ya mencionado (art. 86 CE).

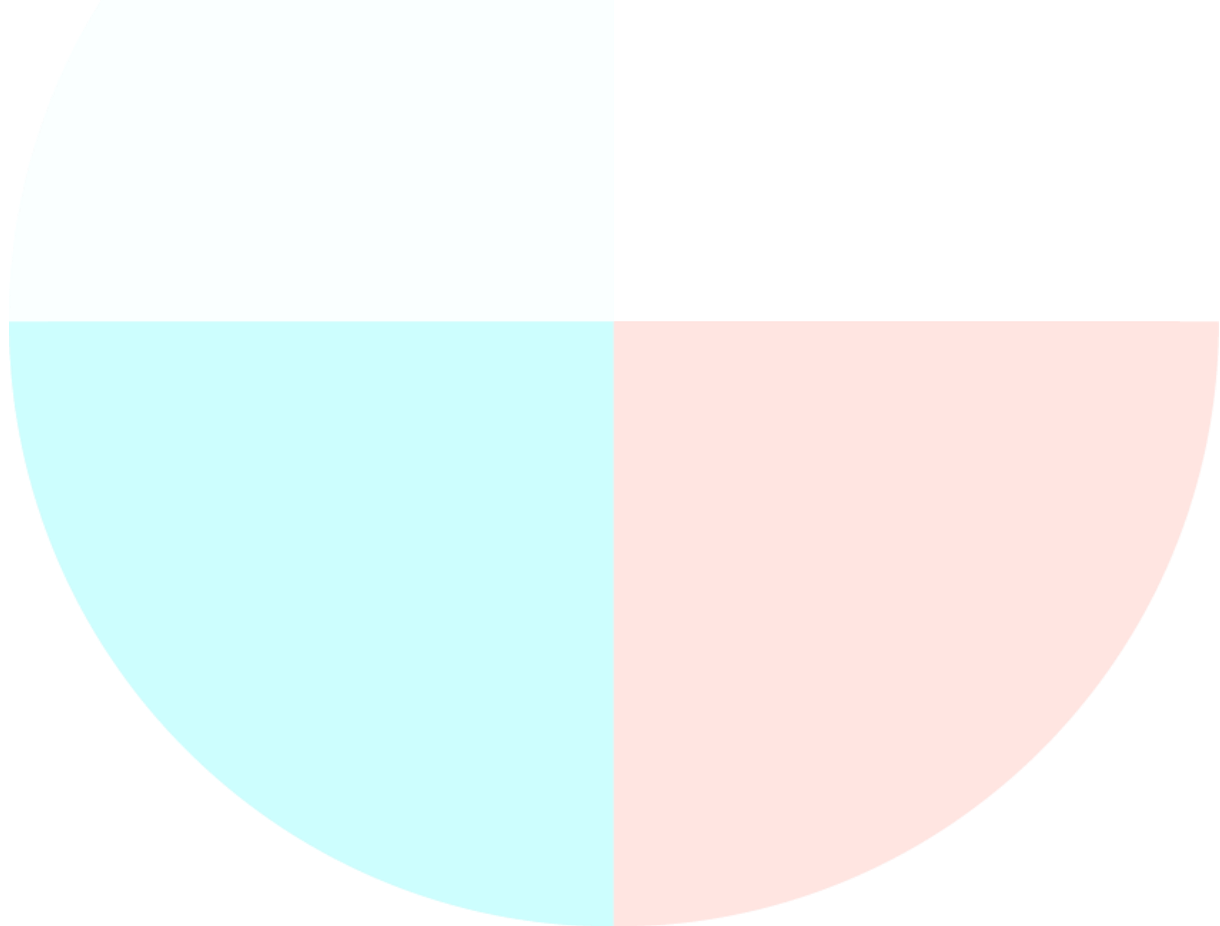
Recordamos que, en relación a todas las normas con rango de ley, que según el art. 127 de la Ley 39/2015, también los órganos de gobierno de las CCAA podrán aprobar normas equivalentes a los Decretos-leyes y a los Decretos Legislativos en su ámbito territorial, de conformidad con lo establecido en la CE y en sus respectivos Estatutos de Autonomía.

4. Control de la legislación delegada

Según el art. 82.6 de la CE: *“Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control”*.

Es decir, hace referencia, por un lado, al control jurisdiccional y, por otro, al control parlamentario de la legislación delegada. Por tanto, enumeramos los **medios de control**:

- Control que puede ser ejercitado por el Tribunal Constitucional, al que corresponde conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley (art. 161 CE).
- La jurisdicción contencioso-administrativa conocerá de las pretensiones que se deduzcan en relación con los Decretos Legislativos cuando excedan los límites de la delegación.
- El dictamen que debe emitir el Pleno del Consejo de Estado, respecto de los proyectos de Decretos Legislativos Este dictamen tiene las características de ser preceptivo, pero no vinculante.



6. EL REGLAMENTO: CONCEPTO, CLASES Y LÍMITES

El **REGLAMENTO** es una norma jurídica escrita emanada del Gobierno, en el ámbito de su competencia, sometida estrictamente al principio de jerarquía normativa, por lo que no puede vulnerar preceptos contenidos en una norma superior.

Se sitúan en la estructura jerárquica normativa por debajo de las leyes y disposiciones con fuerza de ley. Es, por tanto, una norma secundaria, inferior y complementaria respecto de la ley.

El **ejercicio de la potestad reglamentaria** (art. 128.1 Ley 39/2015) corresponde:

- Al **Gobierno de la Nación** (recogido en art. 97 CE).
- A los **órganos de Gobierno de las CCAA**, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos.
- A los **órganos de gobierno locales**, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local.

La potestad reglamentaria está limitada por las leyes. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las CCAA. Sin perjuicio de su **función de desarrollo o colaboración** con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público (art. 128.2 Ley 39/2015).

Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior (art. 128.3 Ley 39/2015).

1. Clases de Reglamentos

Los Reglamentos pueden ser clasificados desde diversos puntos de vista:

(1) Por el **SUJETO de quien proceden** (competencia) los Reglamentos pueden ser:

- **Estatales** (art. 24 LG):

RD
Presidente

- **Reales Decretos del Presidente del Gobierno:** disposiciones y actos cuya adopción venga atribuida al Presidente.

RD Consejo
Ministros

- **Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros:** decisiones que aprueben normas reglamentarias de la competencia de este así como las resoluciones que deban adoptar dicha forma jurídica.

Orden Ministerial

- **Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno**, las disposiciones y resoluciones de tales órganos colegiados. Tales acuerdos revestirán la forma de Orden del Ministro competente o del Ministro de la Presidencia, cuando la competencia corresponda a distintos Ministros.

Orden Ministerial

- **Órdenes Ministeriales, las disposiciones y resoluciones de los Ministros.** Cuando la disposición o resolución afecte a varios Departamentos revestirá la forma de Orden del Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros interesados.

Los reglamentos se ordenarán según la siguiente jerarquía (art. 24.2 LG):

Jerarquía Reglamentos

- 1º: Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en el Consejo de Ministros.
- 2º: Orden Ministerial.

- Autonómicos:

- **Decretos del Consejo de Gobierno.**
- **Órdenes de los Consejeros.**

- Locales:

- **Reglamento orgánico.** Expresan la potestad autoorganizativa (ad intra).
- **Ordenanzas locales** (ad extra).

(2) Por sus **EFFECTOS**, pueden distinguirse:

- Reglamentos jurídicos o propiamente normativos.
- Reglamentos administrativos o de organización.

(3) Por su **RELACIÓN con la ley**, los Reglamentos se clasifican en:

- **Ejecutivos:** responden a la necesidad de completar y desarrollar la ley en que se apoyan, normalmente en virtud de una autorización o mandato expreso de la misma. La Ley, en muchas ocasiones, regula una materia enunciando unos principios básicos y deja a la Administración, para que por medio de un reglamento, desarrolle esas líneas directivas fijadas por el legislador. El desarrollo puede ser total o parcial.

Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carácter general, al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo (art. 129.4 Ley 39/2015).

La aprobación de los reglamentos para el desarrollo y ejecución de las leyes (estatales) corresponde al Consejo de Ministros (art. 5.1.h) LG).

- **Independientes**: son aquéllos que operan sobre ámbitos distintos de los regulados por las leyes. Su ámbito es la materia organizativa, consecuencia de la originaria potestad reglamentaria.
- **De necesidad**: sólo se justifican en función de un estado de necesidad, por ello, incluso en ocasiones se colocan por encima de la ley. Este tipo de medidas excepcionales procederá en las situaciones previstas en el art. 116 de la Constitución, es decir, estado de sitio, alarma o excepción.

Como ejemplo, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma.

2. Límites de la potestad reglamentaria

Los Reglamentos deben observar una serie de límites, de cuyo respeto depende su validez. Si cualquiera de estos límites, legales o extralegales, es rebasado, el Reglamento en cuestión resultará viciado. En este sentido amplio es como hay que entender la expresión habitual “Reglamentos ilegales”.

Estos límites se pueden agrupar en dos categorías:

- **Límites SUSTANCIALES**: afectan al contenido mismo de la norma reglamentaria.
- **Límites FORMALES**: relativos al aspecto externo del Reglamento.

Límites sustanciales

Se entiende que para poder afirmar la validez de un Reglamento debe este superar la confrontación con otras reglas de carácter sustancial que son:

- **El respeto a los principios generales del Derecho y en especial la interdicción de la arbitrariedad.** El art. 103.1 de la CE establece que “*la Administración actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho*”, del cual forman parte, como se deduce del art. 1 del CC, los principios generales del Derecho. Por otra parte, el art. 9.3 de la CE garantiza de manera específica “*la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos*” y, por tanto, de la Administración, que es uno de ellos.
- **Las técnicas de control de la discrecionalidad.** La potestad reglamentaria es una potestad discrecional, por lo que las técnicas de control de dicha discrecionalidad serán aplicables a ella.
- **La materia reglamentaria.** El Reglamento solo será válido si se produce o sobre la materia organizativa interna que es su campo material y directo, no necesitado de habilitaciones legales específicas, o fuera de ese campo, pero utilizando para ello en este caso habilitaciones legales concretas que le hayan abierto esta materia, que en otro caso tendría cerrada. Así el art. 128.2 de la Ley 39/2015 establece que “*sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas*

o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público”.

- **Irretroactividad.** Con apoyo en el art. 9.3 de la CE y en el art. 47.2 de la Ley 39/2015 se dispone que serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas, que entre otros límites *“establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”*. Debemos entender, en sentido contrario, que sí se podrán aplicar con carácter retroactivo cuando resulten más beneficiosas.

Límites formales

Se pueden citar los siguientes:

- **La competencia para emanar Reglamentos:** el art. 97 de la Constitución atribuye expresamente al Gobierno la potestad reglamentaria, pero, a la vez, al establecer la garantía institucional de la autonomía en favor de los municipios, las provincias y las Comunidades Autónomas (arts. 137, 140, 141 y 143) está admitiendo también como contenido de dicha autonomía una potestad normativa propia de esas entidades territoriales, potestad que incluye como mínimo la reglamentaria. Estos son casos de potestad reglamentaria originaria. En la actualidad es el art. 128 de la Ley 39/2015, el que de manera clara señala la atribución de potestad reglamentaria a todas las AAPP.
- **La jerarquía normativa:** es un principio garantizado por el art. 9.3 de la CE. En la cúspide de la pirámide se encuentra la Constitución y, tras ella, la ley; a una y a otra está sometida plenamente la Administración (como precisan los arts. 9.1 y 103.1 de la CE), y por tanto, los Reglamentos (art. 97 de la CE). Según el art. 128, apartados 2 y 3 de la Ley 39/2015 *“Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las CCAA. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior”*.

El principio de jerarquía normativa no se refiere solo a las relaciones entre el Reglamento y la Ley. También los propios Reglamentos están relacionados entre sí jerárquicamente de forma correlativa a la jerarquía que une a los órganos de que proceden. El art. 24.2 de la LG dispone: *“Los Reglamentos se ordenarán según la siguiente jerarquía:*

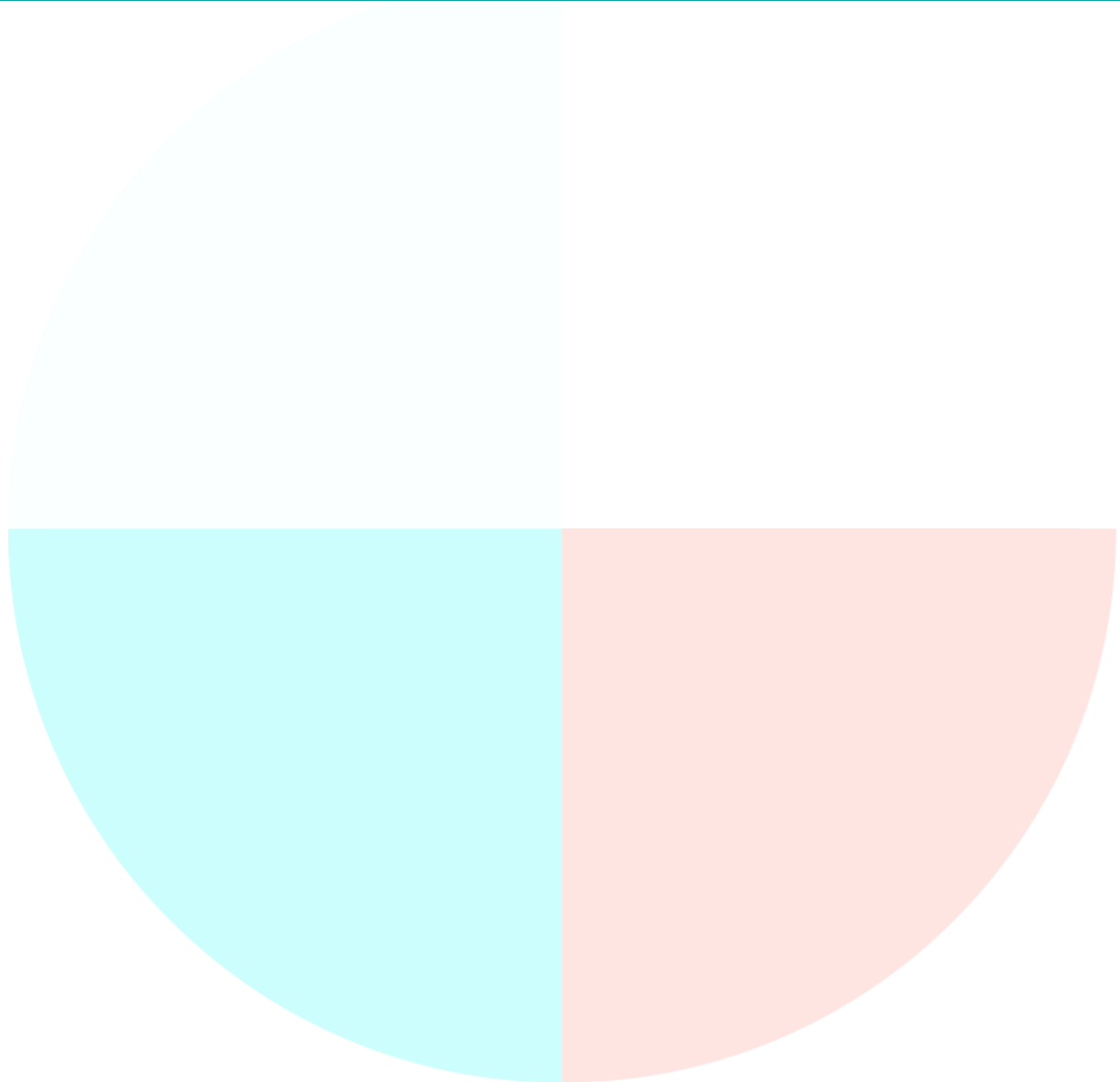
- 1º. Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en Consejo de Ministros.*
- 2º. Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial”.*

- **El procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter general:** El poder reglamentario debe ejercitarse de acuerdo con unos trámites establecidos, que constituyen un procedimiento especial regulado, definido en el art. 26 de la LG.

3. Reglamentos ilegales

El ordenamiento ha de reaccionar necesariamente con medios enérgicos contra el grave ataque que frente a él supone el Reglamento ilegal. Esta reacción será la **nulidad de pleno derecho** del Reglamento ilegal. Así el art. 47.2 de la Ley 39/2015 dispone:

“También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”.



7. OTRAS FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

1. Normas directas no escritas

Costumbre (Derecho consuetudinario)

Norma impuesta por el uso social y sólo aplicable en defecto de ley, siempre que no ataque la moral o el orden público y siempre que resulte probada.

Principios generales del Derecho

Criterios fundamentales que informan el origen y desenvolvimiento de una determinada legislación que, expresados en reglas y aforismos, tienen virtualidad y eficacia propias con independencia de las normas formuladas en el plano positivo.

Son aplicados en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter de informativo del ordenamiento jurídico.

Entre los principios generales del Derecho tenemos la libertad, la justicia, la igualdad (art. 1.1 CE), la dignidad de la persona (art. 10.1 CE) o los principios rectores declarados en el Capítulo Tercero del Título I de la CE.

2. Normas indirectas

Tratados internacionales no incorporados al ordenamiento interno

Acuerdo internacional de voluntades o acuerdo celebrado entre sujetos jurídicos del orden internacional.

Aplicable directamente si están en el ordenamiento jurídico y han sido publicados en el BOE.

Jurisprudencia

La jurisprudencia según el art. 1.6 del CC, se define como *“complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho”*, por lo que, aunque no sea fuente propiamente dicha del derecho español, su facultad para modular la Ley y establecer cuáles han de ser los principios generales del Derecho la hacen fundamental para la práctica del derecho en España.

La jurisprudencia se establece a partir de dos Sentencias que interpreten una norma en igual sentido, emanadas del Tribunal Supremo (órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales) y, cuando se trata de ciertas

materias de competencia limitada a la Comunidad Autónoma (por ejemplo, Derecho foral o especial), de los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidad Autónoma.

Doctrina científica o legal

Opinión reconocida que determinados juristas emiten sobre temas relacionados con el derecho.

3. Derecho comunitario

Las fuentes del Derecho Comunitario son el derecho originario (Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y los Tratados de Adhesión y de modificación), así como el derecho derivado (las Directivas y los Reglamentos).

- **Derecho ORIGINARIO**: Tratado constitutivo de 1951, Tratado de Roma de 1957, modificado por el Acta Única Europea (1986), el Tratado de la Unión Europea o de Maastricht (1992), el Tratado de Ámsterdam (1997), el Tratado de Niza (2001) y el Tratado de Lisboa (2007).
- **Derecho DERIVADO**: según el art. 288 del Tratado De Funcionamiento de la Unión Europea, para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. Los principales instrumentos normativos que emanan de las instituciones comunitarias son los Reglamentos y las Directivas:
 - o Los **REGLAMENTOS** tendrá un alcance general. Son normas obligatorias en todos sus elementos y directamente aplicables en cada Estado miembro. Poseen vigencia en el ordenamiento interno sin necesidad de una norma de desarrollo.
 - o Las **DIRECTIVAS**, a diferencia de los Reglamentos, no son directamente aplicables, sino que los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para su transposición. La Directiva vincula a los Estados en cuanto a los resultados y objetivos a alcanzar, pero no en cuanto a la forma y medios para conseguirlo.
 - o La **DECISIÓN** será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, sólo será obligatoria para éstos.
 - o Las **RECOMENDACIONES** y los **DICTÁMENES** no serán vinculantes.

La incorporación al ordenamiento interno del Derecho Comunitario se produce directamente, dado que, a través del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, se ha producido una cesión de soberanía. En consecuencia, no es precisa ni la ratificación ni la publicación en el BOE para su entrada en vigor, bastando su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.